

1503414-15.2020.8.26.0362

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... legal. A esse respeito:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1503414-15.2020.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503414-15.2020.8.26.0362

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO HENRIQUE CONSTANCIO SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

GUSTAVO HENRIQUE CONSTÂNCIO SILVA foi denunciado e está sendo processado, pois no dia 19 de agosto de 2020, por volta das 16h35min, na avenida Suécia cruzamento com a rua Mário Jacinto, Jd. Nova Odessa, no Município e Comarca de Mogi Guaçu, guardava e trazia consigo, nas imediações de locais de trabalho coletivo, de recreação coletiva, de entidades escolares, de saúde, além de entidades beneficentes e culturais, para tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 129 (cento e vinte e nove) porções de cocaína em pó, embaladas em plástico, pesando cerca de 84,4g (oitenta e quatro gramas e quatro decigramas); droga, conforme faz certo o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 59/61.

O réu apresentou defesa prévia por defensor constituído (fls. 82/83) e a denúncia foi recebida pela decisão de fls. 98/99. Houve citação (fls. 126).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas, com o interrogatório do réu ao final.

As partes se manifestaram em alegações finais.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a materialidade delitiva está demonstrada pelos autos de exibição e apreensão (fls. 10 e 16); pelo auto de constatação preliminar de substância tóxica (fls. 11); laudo de exame químico-toxicológico (fl. 60), laudo pericial de local (fls. 62/68) e por toda a prova oral colhida.

EDSON RODRIGUES DA SILVA disse que estava em patrulhamento e se deparou com o acusado, que já era conhecido dos meios policiais. O agente tentou a fuga, mas foi contido. O parceiro do depoente realizou a busca pessoal e localizou pinos na calça. Na sequência, em uma sacola que o acusado trazia em mãos, localizou mais porções de cocaína. Apreendeu RS 50,00 em notas diversas.

MARCOS FELIPE SALVADOR LEANDRO prestou depoimento no mesmo sentido, confirmando que o acusado carregava uma sacola preta nas mãos e que foi o responsável por localizar pinos na barra da calça do acusado. Na sequência, apreendeu a maior parte das drogas na sacola.

Em juízo, o acusado disse que esteve no local para adquirir droga para seu consumo. Afirma que o dinheiro apreendido lhe foi entregue por sua genitora. Não viu droga em nenhuma sacola, afirmando que não a carregava e que a sacola foi exibida apenas na Delegacia de Polícia, onde os guardas passaram a contar as porções. Já havia sido abordado pelos mesmos guardas civis, mas eles não cometeram nenhum abuso anteriormente.

Com efeito, o depoimento prestado pelos guardas municipais é digno de toda credibilidade, já que devidamente compromissados e inexistentes indícios de interesse dos servidores públicos em prejudicar pessoa inocente. De acordo com a jurisprudência:

PROVA - Depoimento policial - Eficácia - Mera condição de agente público que não torna a testemunha impedida ou suspeita - Precedentes - Recurso improvido.

(Apelação Criminal n. 974.712-3/9-00 - Santos - 14ª Câmara Criminal - Relator: Sérgio Ribas - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 4.191).

PROVA - Depoimento policial - Valor - Credibilidade e responsabilidade equivalentes à palavra dos civis, máxime quando corroboradas pelo conjunto probatório - Precedentes - Recurso improvido. (Apelação Criminal n. 497.707-3/9-00 - Santos - 5ª Câmara Criminal - Relator: Marcos Zanuzzi - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 13.332).

No caso dos autos, as provas carreadas permitem a formação da convicção de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade e forma de embalagem da droga apreendida.

Anote-se que não há nenhuma prova que indique que os fatos não ocorreram da forma relatada pelos guardas civis, ou que eles teriam deliberadamente forjado o flagrante, imputando ao acusado a posse da significativa quantidade de drogas apreendidas nas vestes e em uma sacola que o acusado segurava.

Veja-se que não há nenhum indício que aponte a veracidade da versão apresentada pelo acusado no sentido de que a sacola "apareceu apenas na Delegacia de Polícia", e que não era quem a portava com as porções em seu interior.

Ao contrário disso, os guardas civis relataram com segurança que a sacola onde localizada a maior parte das porções estava nas mãos do acusado, e não em nenhum outro local, como alegado pelo acusado.

Mais do que isso, não existe prova nenhuma de interesse dos servidores públicos em deliberadamente prejudicar o acusado, imputando-lhe a posse das porções de cocaína sem que realmente tenham sido localizadas na posse do increpado.

Bem de ver que o tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06 é misto alternativo, de modo que, comprovado que o acusado trazia consigo quantidade expressiva de droga acondicionada de forma fracionada, deve ser dado como incurso naquele preceito legal. A esse respeito:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663). "Ademais, é sabido que o tráfico de entorpecentes é delito de ação múltipla ou

conteúdo variado cuja consumação se contenta com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou simples porte da droga, desde que não seja para consumo pessoal. Daí não haver falar em mero auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ, HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 31/08/2011).

Não há que se acolher o pedido desclassificatório, pois é incabível atribuir ao acusado apenas a posse das sete porções de cocaína que alega que se destinavam a seu consumo pessoal, devendo ser reconhecida a propriedade da totalidade das porções, eis que os guardas civis visualizaram e confirmaram, em juízo, que ele carregava a sacola em que apreendidas as mais de cem porções.

Nesse contexto, o total apreendido (129 porções) é incompatível com a pretendida desclassificação.

Passo à dosagem da pena, em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Em primeira fase, entendo que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, de modo que fixo a pena privativa de liberdade em seu patamar mínimo, isto é, em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, anotando que a massa líquida indicada no laudo pericial é de 24 gramas (fls. 60), quantidade que não se compatibiliza com o invocado pedido ministerial de exasperação.

Em segunda fase, ausentes agravantes, mas presente a atenuante da menoridade relativa, sem reflexo sobre a pena aplicada, pois já estipulada no mínimo legal.

Em terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da lei n. 11.343/06, já que o laudo pericial (fls. 62/68) revela que nas imediações do local onde os fatos ocorreram estão situadas a Secretaria de Promoção Social e a Associação dos Deficientes Visuais de Mogi Guaçu, empresa SITI, estabelecimento de ensino e praça pública, o que evidentemente facilita a propagação do tráfico de drogas devido ao maior fluxo de pessoas.

Aliás, a lei não exige que aqueles sejam os locais especialmente visados pelo infrator, bastando a proximidade física. A esse respeito:

A traficância era exercida em local inequivocamente próximo das escolas “Zumira” e “Rubens Leme Asprino” (distava aproximadamente 800 metros da primeira e 490 metros da segunda - vide fls. 74/7), sendo que para a incidência da majorante referente ao artigo 40, inciso III, não exige a lei que o estabelecimento de ensino seja especialmente visado pelo infrator, bastando, tão somente, a proximidade física e o conhecimento dessa proximidade. (TJSP, Apelação n. 0004114-44.2011.8.26.0083, Relator Des. Geraldo Wohlers, julgado aos 26.2.2013, 3ª Câmara de Direito Criminal) Ainda sobre essa questão, o Col. Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se pronunciar no sentido de que “(...) O tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local (...). Destarte, não procede a alegação da impetrante no sentido de que não há demonstrativo de relação evidente entre a conduta dos pacientes e as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos de ensino, uma vez que é irrelevante o fato de haver ou não intenção dos acusados de atingir os frequentadores do estabelecimento. Para incidência da mencionada causa de aumento de pena, basta a proximidade física do local onde o tráfico estava sendo praticado e o estabelecimento de ensino, o que ficou corretamente assentado pelas instâncias ordinárias.” (HC 116.929/SP, 1ª Turma, relator Min. Luiz Fux, julgado aos 15.10.2013).

No mesmo sentido, posiciona-se o E. Superior Tribunal de Justiça, que em precedente desta Comarca decidiu que: No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento no sentido de ser desnecessária, para a incidência da majorante do artigo 40, III, da lei de drogas, a comprovação de que o comércio de ilícito de substâncias entorpecentes vise atingir os alunos do estabelecimento, bastando, para sua incidência, que a prática da traficância tenha ocorrido nas imediações da escola (RESP n. 1.774.414/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22.2.2019).

Por estes fundamentos, majoro a pena em 1/6, resultando pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias multa.

Ainda em terceira fase, não incide a causa de diminuição de pena prevista no artigo

33, § 4º, da lei n. 11.343/06, porque o acusado ostenta anteriores execuções de medidas socioeducativas (fls. 29), as quais foram extintas nos meses de setembro e novembro de 2019, vale dizer, menos de um ano antes da prisão em flagrante do acusado pelo fato aqui apurado.

Nesse caso, em que a extinção das medidas socioeducativas é contemporânea à prisão do acusado, entendo que é viável impedir a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da lei n. 11.343/06. A esse respeito:

Ainda nessa etapa, no meu ponto de vista, realmente não é caso de se aplicar o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas ao apelante, já que compartilho do entendimento do Juiz sentenciante no sentido de que ficou demonstrado que ele se dedicava a atividades criminosas, em razão de ter admitido que vendia drogas há uma semana, além de já possuir um registro por ato infracional perpetrado quando adolescente, equiparado ao tráfico (TJSP, Autos n. 007605-85.2017, Relator Des. Nelson Fonseca Júnior, 10ª Câmara de Direito Criminal, julgado aos 23/8/2018).

"[a] existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais" (STJ, AgRg no REsp nº 1.560.667- SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. em 17.10.2017, DJe 23.10.2017).

Como já dito, ostentando envolvimento em atividades criminosas, o agente não faz jus ao benefício destinado a iniciantes na seara delitiva, razão pela qual fica afastada a aplicação da minorante mencionada.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal.

De acordo com o total de pena imposta e porque favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto. Nesse sentir: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. REGIME FECHADO COM BASE NA HEDIONDEZ DO DELITO. DESCABIMENTO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - In casu, v. acórdão impugnado fundamentou o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava a atividades criminosas (traficância), em razão não somente pela quantidade de drogas apreendidas, mas também pelas circunstâncias em que se deu a prisão, bem como constatarem que não se tratava de traficante ocasional. Tudo isso, são elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição, como reclama a impetrante, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. III - Considerada a quantidade de pena aplicada (5 anos de reclusão), bem como fixada a pena-base no mínimo legal, em virtude da análise favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, constata-se a existência de constrangimento ilegal decorrente da imposição do regime fechado, de sorte que o paciente faz jus ao regime inicial semiaberto, o qual se revela como o mais adequado à prevenção e à repressão do delito em tela, conforme o art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. IV - Mantida a pena cominada ao paciente em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, resta prejudicado o pedido de substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos, pois não preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 44 do Código Penal. Agravo regimental desprovido.

(....)

No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, insta consignar que o Pleno do eg. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 111.840/ES, por maioria de

votos, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a nova redação dada pela Lei n. 11.464/2007, por ofender a garantia constitucional de individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal). Afastou, dessa forma, a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para os condenados pela prática de crimes hediondos e dos demais delitos a eles equiparados. Em tal contexto, nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o Julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e, em se tratando dos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como no caso, deverá levar em conta a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). Na hipótese, verifica-se nos excertos acima colacionados que o v. acórdão impugnado manteve o regime prisional fechado, amparando-se tão somente na hediondez do delito (tráfico de drogas), sem indicar elementos concretos dos autos que demonstrassem a real necessidade de imposição de regime prisional mais gravoso, o que vai de encontro ao teor dos Enunciados ns. 718 e 719 da Súmula do STF, bem como do Enunciado n. 440 da Súmula do STJ, que assim dispõem:

(....)

Sob essa perspectiva, considerada a quantidade de pena aplicada (5 anos de reclusão), bem como fixada a pena-base no mínimo legal, em virtude da análise favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, constata-se a existência de constrangimento ilegal decorrente da imposição do regime fechado, de sorte que o paciente faz jus ao regime inicial semiaberto, o qual se revela como o mais adequado à prevenção e à repressão do delito em tela, conforme o art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. (Superior Tribunal de Justiça, AgRg no HABEAS CORPUS Nº 604.250 - SP, julgado aos 6/10/2020, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma)

Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do total da pena imposta.

Por estas razões, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO GUSTAVO HENRIQUE CONSTÂNCIO SILVA à pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 583 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06.

O réu poderá aguardar o processamento de eventual recurso em liberdade.

Decreto o perdimento do numerário apreendido, pois consequência lógica da condenação imposta e porque não comprovada sua origem lícita (fls. 57).

Custas ex lege, observada eventual gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

PRI.

Mogi Guacu, 28 de março de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA